

1501755-70.2019.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... do delito de associação para o tráfico de drogas não pode se dar pela dedução abstrata de que o tráfico de droga realmente aconteceu, é preciso a prova de um fato concreto que faça permitir que concretamente houve a intenção de se associarem para prática do tráfico de substância considerada como droga (Portaria ANVISA nº 344/98). Neste sentido:

TRÁFICO - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

1ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501755-70.2019.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501755-70.2019.8.26.0599 - Controle nº 2019/002417

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL ISAC DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

I - RELATÓRIO

Vistos,

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra GABRIEL ISAC DA SILVA, Vulgo "Biel", WEVERTON SOARES DOS SANTOS, Vulgo "Tom" e PAULO CÉSAR ELIZIÁRIO DOS SANTOS tendo-os por incurso nos artigos 35, caput, e 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, imputando-lhes os seguintes fatos: que em data não especificada até 07 de dezembro de 2019, previamente ajustados e em unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.

Consta também que, no dia 07 de dezembro de 2019, por volta das 01h, na Rua João Nunes de Moraes, nº 541, nesta cidade e comarca, os acusados traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, 16 eppendorfs contendo cocaína (massa líquida de 11,4g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, fotografia de fl. 18, auto de constatação de fls. 19/20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 172/175.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 [fls. 272/273].

Os réus foram presos em flagrante [fls. 1/2], alvará de soltura [fls. 143/154].

Devidamente notificados e citados [fls. 227, 229 e 245], os réus, por meio de defensora dativa [fls. 253/255] apresentaram resposta à acusação [fls. 258/271].

Foi designada audiência a ser realizada por videoconferência [fls. 272/273] na qual foram ouvidas as testemunhas e ao final os réus foram interrogados.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal dos réus, pugnano pelas condenações nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria da pena (fls. 385/405).

A Defesa de todos os réus, em suas razões finais, pleiteou pela absolvição ou diminuição da pena (fls. 380/382, 409/412 e 413/418).

O acusado Gabriel, em suas razões finais, sustentou que apenas estava na hora e local errado, apesar de dividir o aluguel do local do crime, mas não teria participação nos delitos de tráfico (fls. 380/382).

O acusado Paulo, em suas razões finais, sustentou que desconhecia que no local havia tráfico de drogas e nada foi encontrado em seu poder. Requer que prevaleça o in dubio pro reo (fls. 409/412).

Por fim, o acusado Weverton, em suas razões finais, sustentou que as denúncias destoam das denúncias recebidas, bem como nada foi encontrado em seu poder. No caso de condenação requereu a redução da pena (fls. 413/418).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante [fls. 01/02], pelo boletim de ocorrência [fls. 10/15], pelo auto de exibição e apreensão [fls. 16/18], pelo laudo de exame de constatação preliminar [fls. 19/20], laudo de exame químico toxicológico [fls. 172/175]. além da prova oral produzida em juízo.

A testemunha Wilson dos Santos Cunha, policial militar, declarou que juntamente com seu colega de farda realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando receberam informações, na forma de denúncia anônima, por pessoa que preferiu não se identificar por medo de represálias, de que no imóvel situado no numeral 541 da Rua João Nunes de Moraes, ao lado de uma barbearia, alguns indivíduos estariam realizando tráfico de drogas de maneira reiterada, sendo que um dos autores seria um indivíduo de cútis parda, magro, com um "caroço" na testa, alcunhado "Biel". Com o fito de confirmar as informações passaram a observar a residência com uma determinada distância, quando notaram a aproximação de um indivíduo ocupando uma motocicleta, o qual parou em frente ao numeral denunciado e passou a conversar com dois indivíduos que saíram de dentro do imóvel, sendo que, diante da fundada suspeita, resolveram realizar abordagem de todos para averiguação. Identificaram então o motociclista como sendo Lauro Batista Dos Santos, o qual alegou que estava ali para a compra de entorpecentes, visto ser usuário de drogas e havia, inclusive, voltado a usar drogas na presente data, contudo, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Outro identificado foi a pessoa de Gabriel Isac da Silva, cujas características físicas condiziam com as denúncias, sendo que em seu poder foram encontrados dois pinos plásticos, tipo eppendorf, contendo pó branco semelhante a cocaína, bem como cerca de R\$50,00 em notas miúdas. O terceiro, identificado como Weverton Soares dos Santos trazia consigo tão somente a quantia aproximada de R\$74,00 em dinheiro, também trocado em notas de pequeno valor.

Questionados a respeito dos fatos, Gabriel e Weverton se limitaram, inicialmente, a negar qualquer envolvimento com tráfico, contudo, durante entrevista em separado, Gabriel acabou por confessar que efetivamente estavam expondo drogas a venda, o que motivou a entrada na residência, onde foram encontrados, sobre o sofá, acondicionados em plástico transparente, outros 14 pinos idênticos e outros 191 pinos vazios. Durante as averiguações, aproximou-se um indivíduo se dizendo dono da residência, o qual foi identificado como Paulo Cezar Eliziário dos Santos, o qual disse desconhecer a existência de drogas, mas confirmou ter autorizado as pessoas de Gabriel e Weverton a residirem consigo, apesar de tê-los conhecido recentemente, não sabendo esclarecer qualquer informação sobre qual atividade Gabriel e Weverton realizavam para se sustentar.

A testemunha Caique Augusto Machado Lagatta, policial militar, corroborou com as alegações prestadas por seu colega de farda, acrescentando que o local onde as

drogas estavam escondidas no imóvel era exposto e praticamente impossível de não serem vistas. Ademais, o proprietário informou ser residente no local. Afirma que o acusado Paulo César não se mostrou surpreso com a abordagem policial no local. O réu Weverton Soares dos Santos, na fase policial, em seu interrogatório fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e só manifestar-se em juízo [fls. 7]. Em juízo disse que os 14 pinos não existiram, que apenas com Gabriel é que tinham dois pinos. Aduziu que tinham pinos vazios guardados dos entorpecentes que usava para jogar posteriormente. Confirma que o Gabriel é o "Biel". Não conhecia os policiais que realizaram a prisão. Afirma que os policiais abordaram os acusados dentro de casa e não na calçada. Confirma que o local é conhecido como ponto de tráfico e moravam no local há cerca de 5 meses. Acrescenta que o depoente e Gabriel estavam empregados, bem como que Paulo morava a pouco tempo no local, pois havia brigado com sua esposa.

O réu Paulo César Elizário dos Santos, na fase policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e de só manifestar-se em juízo [fls. 8]. Em juízo, por sua vez, não compareceu para ser interrogado.

O réu Gabriel Isac da Silva, na fase policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e de só manifestar-se em juízo [fls. 9]. Em juízo, por sua vez, negou os fatos. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado com o depoente, com os demais réus ou na casa. Aduziu que vieram, ele e Weverton, de Hortolândia para morarem em São Pedro e desconhece que o local era ponto de venda de drogas. Contou que Paulo foi quem ajudou o depoente a encontrar a casa onde moravam. Negou a existência de apelidos dos 3 envolvidos. Aduz que residia no local há pouco tempo, cerca 3 a 4 meses, bem como confirma conhecer o acusado Weverton desde criança. Alega ter conhecido o acusado Paulo na cidade. Acrescenta que a casa tinha apenas 3 cômodos onde moravam os 3 acusados.

Essa é a prova oral colhida nos autos.

Diante do contexto probatório é forçoso concluir pela condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas nos termos da denúncia, notadamente pelo depoimento dos policiais militares.

O crime de tráfico é crime material, logo, exige a apreensão da droga e a realização de perícia a fim de constatar-se a existência da droga e comprovação do resultado naturalístico. Já o crime de associação para o tráfico é crime formal cuja tipificação não necessita da existência efetiva da droga, basta a sociedade entre os envolvidos com o fim específico de praticar os delitos previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGA COM O PACIENTE.

PRESCINDIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52 DESTA CORTE. 1. Não obstante a materialidade do crime de tráfico pressuponha apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza formal, sua materialidade pode advir de outros elementos de provas, como por exemplo, interceptações telefônicas. 2. No caso dos autos, com a prisão da corré, foram apreendidos vários objetos, dentre os quais telefones celulares com registros de números de pessoas envolvidas com o tráfico. A partir de tais registros, foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas, oportunidade em que se constatou o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, sendo ele eventual responsável pela manufatura e fornecimento da droga. 3. A periculosidade concreta do paciente a justificar a segregação cautelar ficou demonstrada diante da grande quantidade de droga – por volta de 345 Kg (trezentos e quarenta e cinco quilos) de maconha –, da considerável quantia em dinheiro – R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) – e das armas apreendidas em poder da quadrilha. 4. Trata-se, ainda, de extensa organização criminosa responsável pelo domínio do tráfico e disseminação de entorpecente em Salvador e outros municípios do Estado da Bahia, facção da qual alguns integrantes são, inclusive, policiais civis. 5. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa,

consoante disciplina o enunciado de Súmula nº 52 desta Corte. 6. Ordem denegada (Brasil. STJ. HC nº 148480/BA. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 07.06.2010). Contudo, apesar de não exigir a efetiva realização do tráfico é preciso haver elementos suficientes a demonstrar que, de fato, existe a finalidade específica de se associarem a fim de praticar as figuras típicas do artigo 33 da Lei 11.343/06. Neste contexto, têm-se que a tipificação do delito de associação para o tráfico de drogas não pode se dar pela dedução abstrata de que o tráfico de droga realmente aconteceu, é preciso a prova de um fato concreto que faça permitir que concretamente houve a intenção de se associarem para prática do tráfico de substância considerada como droga (Portaria ANVISA nº 344/98). Neste sentido: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Quadro probatório frágil - Ausência de provas no tocante ao crime de associação - Delito autônomo que demanda comprovação do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância - Inexistência de provas quanto ao vínculo associativo - Absolvição que se impõe - PENA - Possibilidade de aplicação da benesse do art. 33, § 4º, L. 11.343/06 na fração máxima, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido - (voto n. 33406) (Brasil. TJ-SP. Ap. Nº 0009418-94.2015.8.26.0176. Rel. Des. Newton Neves. J. 22.08.2017).

Na hipótese dos autos, os depoimentos dos policiais militares são harmoniosos acerca da apreensão da droga em poder dos acusados, tanto na fase policial como em juízo. Com efeito, foram firmes e coesos ao sustentarem que no dia dos fatos receberam denúncia anônima dando conta que no local dos fatos havia comércio ilícito de entorpecentes praticado por alguns indivíduos, sendo um deles de alcunha "Biel", que os policiais foram ao local e ao chegarem, com o fito de confirmar as informações, passaram a observar a residência com uma determinada distância, quando notaram a aproximação de um indivíduo ocupando um motociclo, o qual parou em frente ao numeral denunciado e passou a conversar com dois indivíduos que saíram de dentro do imóvel, sendo que, diante da fundada suspeita, resolveram realizar abordagem de todos para averiguação, e diante disso soube-se que o indivíduo da motocicleta estava presente naquele local para a compra dos entorpecentes, e tendo um dos réus confessado motivou a investigação dos policiais na residência a qual fora encontrada sobre o sofá, acondicionados em plástico transparente, e outros 14 pinos idênticos e outros 191 pinos vazios.

A harmonia dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo é evidente. Os depoimentos trazem de forma uníssona o modo da ocorrência na visão de cada policial, sendo que relataram que abordaram inicialmente um dos acusados no local dos fatos e com ele apreenderam uma quantia de drogas.

Ressalte-se que não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte (CF, art. 144), apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, "(o) depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996).

Dessa forma, a apreensão em quantidade de entorpecentes evidencia a mercancia da droga.

A finalidade da traficância é, portanto, inafastável, sendo insubsistentes as alegações diante das demais circunstâncias da apreensão.

Isso porque houve apreensão de drogas 16 eppendorfs contendo cocaína (massa líquida

de 11,4g), compartimentados em porções próprias para a mercancia. Além disso, mais de 200 microtubos vazios foram apreendidos no local, o que demonstra a rotineira prática delitiva do tráfico.

Nesse contexto fático, pois, descabida eventual desclassificação do delito de tráfico para o de porte de drogas para o consumo pessoal, pois as circunstâncias da apreensão da droga com os réus são próprias da conduta do traficante.

As narrativas dos réus se contradizem, pois Gabriel negou a existência de drogas, ao passo que Weverton afirmou que Gabriel trazia consigo duas porções de cocaína para uso de ambos, bem como que os policiais apresentaram todas as drogas apreendidas, embora tenha negado o conhecimento da origem de todas elas.

Se não bastasse, Gabriel disse que Paulo teria encontrado a casa para os três residirem juntos, o que fazia cerca de cinco meses da data dos fatos, ao passo que Weverton relatou que somente estaria ajudando Paulo, que conhecia há pouco tempo, pois ele havia pedido ajuda porque havia brigado com a esposa, sendo que Paulo residia no local há pouco tempo.

Veja-se que Gabriel e Weverton apresentam narrativas diferentes, contraditórias e excludentes a respeito de Paulo, não encontrando amparo no conjunto probatório.

Não encontra guarida nos autos, outrossim, a alegação de que o acusado Paulo desconhecia o envolvimento dos demais acusados com o tráfico e com ele não se coadunava, pois a testemunha Caique deixou claro que as drogas eppendorfs estavam em local de fácil visualização, bem como o acusado ouvido em Juízo Weverton confirmou que o local é conhecido ponto de tráfico drogas.

Portanto, resta evidenciado que apesar de Paulo não estar portando entorpecentes no momento da abordagem, associou-se com os demais acusados no intuito de praticar o tráfico de drogas no local, bem como agiu com dolo de ter em depósito as drogas encontradas, e materiais correlatos, ainda assumiu o risco de que fossem entregues para consumo ou fornecidas as drogas.

No mesmo sentido quanto ao acusado Weverton, pois apesar de não trazer a droga consigo, morava no local e era amigo íntimo de Gabriel com o qual os policiais encontraram a droga em seu poder. Ademais, no imóvel de residência foram encontradas mais drogas prontas para o comércio. Desta feita, não é crível a tese de que não sabia da traficância ou dela não se coadunou, até porque no momento da abordagem dos policiais Weverton estava junto com Gabriel que vendia o entorpecente para terceiro.

Assim, pois, é de se reconhecer que os réus guardavam, entregavam para consumo, ofereciam a venda e mantinham em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, condutas que se amoldam à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11343/2006.

Portanto, as provas dos autos demonstram que os acusados praticaram crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por sua vez, relativamente ao crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, de igual modo imperiosa a condenação dos réus.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige-se, além do concurso mínimo de duas pessoas, prévio ajuste entre agentes que comunguem o propósito de, reiteradamente ou não, praticarem as condutas previstas nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11343/2006, com certo grau de estabilidade e permanência, elemento subjetivo específico exigido para a distinção de mera prática delitiva em concurso de agentes, sendo prescindível a efetiva realização das condutas criminosas referidas, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato.

Nesse sentido, há elementos de convicção demonstrando que os réus possuíam vínculo prévio especialmente orientado à prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

No caso dos autos, constata-se a convergência de vontades ou a colaboração entre eles para a prática delitiva, porquanto as testemunhas narraram que foi observado vínculo na conduta dos réus, bem como Weverton e Gabriel apresentaram versões contraditórias em Juízo em clara comunhão de vontades de deturpar as provas dos autos.

Ademais, é fato que os acusados moravam no local há cerca de 5 meses, sendo que nenhum dos acusados comprovou documentalmente nos autos ou através de testemunhas o alegado emprego/atividade lícita. Logo, a mudança dos acusados para o local dos

fatos se coaduna com o início das denúncias de traficância o que revela o intuito dos três acusados em se mudar para este urbe para se associarem na finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas.

Assim, demonstrada a materialidade dos delitos e a responsabilidade dos acusados, de rigor às condenações.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

1) Quanto ao réu Weverton Soares dos Santos:

- Crime de tráfico:

A natureza e a elevada quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda, porque os efeitos deletérios da cocaína ao usuário e ao meio familiar e social em que se insere são por todos conhecidos, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. Desse modo, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo. O acusado não possui maus antecedentes [Certidão de Objeto e Pé - fls. 101]. A conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é favorável ao réu. No exame da personalidade "deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu" (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588), o que, como se vê, demandaria prova técnica não produzida ou, pelo menos, robusto material probatório revelador de que o réu apresenta estereótipos de quem propende a delinquir, o que não se verifica objetivamente, sendo, por isso, circunstância incapaz de agravar a pena-base (cf. STJ - HC n. 233.077, rel. Min. Laurita Vaz). O motivo do crime integra sua definição típica, isto é vantagem patrimonial em detrimento da saúde pública e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. Irrelevante o comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixa-se a pena base acima do mínimo legal com acréscimo de 1/6 em 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Em segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes a sopesar.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por outro lado, não incide na espécie. Isto porque o réu se dedicava à traficância em local conhecido como ponto de venda de drogas e, ainda, estava na posse de quantidade razoável de entorpecentes, sendo forçoso concluir que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, assim, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa. Além disso, realizava o tráfico juntamente com outras duas pessoas.

Imperiosa a fixação do regime inicial fechado na hipótese e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da existência de circunstância judicial desfavorável e pelo fato de ter sido condenado pela prática de crime hediondo. Ademais, é necessária resposta penal mais efetiva, como forma de retribuição proporcional à gravidade da conduta, pois, a considerar a quantidade das drogas apreendidas, o regime inicial mais brando e eventual substituição da reprimenda corporal por penas alternativas não se revelam suficientes para a reprovação e a prevenção do delito em comento.

Assim, pois, a pena definitiva é de 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

- Crime de associação para o tráfico:

A natureza e a elevada quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda, porque os efeitos deletérios da cocaína ao usuário e ao meio familiar e

social em que se insere são por todos conhecidos, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. Desse modo, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo. O acusado não possui maus antecedentes [Certidão de Objeto e Pé fls. 101]. A conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é desfavorável ao réu. No exame da personalidade “deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio accidental na vida do réu” (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588), o que, como se vê, demandaria prova técnica não produzida ou, pelo menos, robusto material probatório revelador de que o réu apresenta estereótipos de quem propende a delinquir, o que não se verifica objetivamente, sendo, por isso, circunstância incapaz de agravar a pena-base (cf. STJ – HC n. 233.077, rel. Min. Laurita Vaz). O motivo do crime integra sua definição típica, isto é vantagem patrimonial em detrimento da saúde pública e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. Irrelevante o comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão com 816 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes para considerar.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, à míngua do pleno esclarecimento da condição econômica do réu.

Imperiosa a fixação do regime inicial fechado na hipótese e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da existência de circunstância judicial desfavorável e pelo fato de ter sido condenado por associação de prática de crime hediondo. Ademais, é necessária resposta penal mais efetiva, como forma de retribuição proporcional à gravidade da conduta, pois, a considerar a quantidade das drogas apreendidas, o regime inicial mais brando e eventual substituição da reprimenda corporal por penas alternativas não se revelam suficientes para a reprovação e a prevenção do delito em comento.

2) Quanto ao réu Paulo César Eliziário dos Santos:

- Crime de tráfico:

A natureza e a elevada quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda, porque os efeitos deletérios da cocaína ao usuário e ao meio familiar e social em que se insere são por todos conhecidos, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. Desse modo, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo. O acusado possui maus antecedentes [Certidão de Objeto e Pé processos nº 0016489-45.2008.8.26.0451; 0031407-54.2008.8.26.0451; 0036344-73.2009.8.26.0451; 0010827-63.1999.8.26.0533]. A conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é favorável ao réu. No exame da personalidade “deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio accidental na vida do réu” (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588), o que, como se vê, demandaria prova técnica não produzida ou, pelo menos, robusto material probatório revelador de que o réu apresenta estereótipos de quem propende a delinquir, o que não se verifica objetivamente, sendo, por isso, circunstância incapaz de agravar a pena-base (cf. STJ – HC n. 233.077, rel. Min. Laurita Vaz). O motivo do crime integra sua definição típica, isto é vantagem patrimonial em detrimento da saúde pública e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. Irrelevante o comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixa-se a pena base acima do mínimo legal com acréscimo de 3/6, que se

justifica em vista da existência de muitos processos anteriores levados em consideração como maus antecedentes, em 7 anos e 6 meses de reclusão com 750 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Em segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes a sopesar.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deste modo, mantém-se a pena previamente estabelecida, tornando-a definitiva em à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão com 750 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Imperiosa a fixação do regime inicial fechado na hipótese e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da existência de circunstância judicial desfavorável e pelo fato de ter sido condenado pela prática de crime hediondo. Ademais, é necessária resposta penal mais efetiva, como forma de retribuição proporcional à gravidade da conduta, pois, a considerar a quantidade das drogas apreendidas, o regime inicial mais brando e eventual substituição da reprimenda corporal por penas alternativas não se revelam suficientes para a reprovação e a prevenção do delito em comento.

- Crime de associação para o tráfico:

A natureza e a elevada quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda, porque os efeitos deletérios do crack ao usuário e ao meio familiar e social em que se insere são por todos conhecidos, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. Desse modo, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo. O acusado possui maus antecedentes [Certidão de Objeto e Pé processos nº 0016489-45.2008.8.26.0451; 0031407-54.2008.8.26.0451; 0036344-73.2009.8.26.0451; 0010827-63.1999.8.26.0533]. A conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é favorável ao réu. No exame da personalidade “deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu” (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588), o que, como se vê, demandaria prova técnica não produzida ou, pelo menos, robusto material probatório revelador de que o réu apresenta estereótipos de quem propende a delinquir, o que não se verifica objetivamente, sendo, por isso, circunstância incapaz de agravar a pena-base (cf. STJ – HC n. 233.077, rel. Min. Laurita Vaz). O motivo do crime integra sua definição típica, isto é vantagem patrimonial em detrimento da saúde pública e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. Irrelevante o comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixa-se a pena base acima do mínimo legal com acréscimo de 3/6, que se justifica em vista da existência de muitos processos anteriores levados em consideração como maus antecedentes, em 4 anos e 6 meses de reclusão com 1050 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes para considerar.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, à míngua do pleno esclarecimento da condição econômica do réu.

3) Quanto ao réu Gabriel Isac da Silva

- Crime de tráfico:

A natureza e a elevada quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda, porque os efeitos deletérios de cocaína ao usuário e ao meio familiar e social em que se insere são por todos conhecidos, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. Desse modo, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo. O acusado não possui maus antecedentes. A conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é favorável ao réu. No exame da personalidade “deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-

social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu" (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588), o que, como se vê, demandaria prova técnica não produzida ou, pelo menos, robusto material probatório revelador de que o réu apresenta estereótipos de quem propende a delinquir, o que não se verifica objetivamente, sendo, por isso, circunstância incapaz de agravar a pena-base (cf. STJ – HC n. 233.077, rel. Min. Laurita Vaz). O motivo do crime integra sua definição típica, isto é vantagem patrimonial em detrimento da saúde pública e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. Irrelevante o comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixa-se a pena base acima do mínimo legal com acréscimo de 1/6 em 5 anos e 10 meses de reclusão, com 583 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no artigo 65, I do Decreto Lei nº 2.848, devido ao réu ser menor de 21 anos na época dos fatos, diminuo a pena em 1/6. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 5 anos de reclusão, com 500 dias-multa,, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

- Crime de associação para o tráfico:

A natureza e a elevada quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda, porque os efeitos deletérios do crack ao usuário e ao meio familiar e social em que se insere são por todos conhecidos, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. Desse modo, a culpabilidade, entendida como grau maior ou menor de reprovabilidade da conduta no caso concreto, é anormal ao tipo. O acusado não possui maus antecedentes. A conduta social, à míngua de elementos de prova desabonadores, é desfavorável ao réu. No exame da personalidade "deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu" (Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, v. 1, 12ª ed., Saraiva, 2008, p. 588), o que, como se vê, demandaria prova técnica não produzida ou, pelo menos, robusto material probatório revelador de que o réu apresenta estereótipos de quem propende a delinquir, o que não se verifica objetivamente, sendo, por isso, circunstância incapaz de agravar a pena-base (cf. STJ – HC n. 233.077, rel. Min. Laurita Vaz). O motivo do crime integra sua definição típica, isto é vantagem patrimonial em detrimento da saúde pública e, portanto, a necessária censura consta na pena mínima abstrata. As circunstâncias do crime são intrínsecas ao delito não exigindo maior reprimenda. As consequências do crime são inerentes à figura típica. Irrelevante o comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão com 816 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no artigo 65, I do Decreto Lei nº 2.848, devido ao réu ser menor de 21 anos na época dos fatos, diminuo a pena em 1/6. Assim, fixo a pena em 3 anos de reclusão com 700 dias-multa, no valor mínimo legal indicado no art. 43 da Lei n.º 11.343/06, corrigido monetariamente.

Em terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso material da crimes as penas devem ser somadas.

Do regime de cumprimento:

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico (cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli). Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, "quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado

(necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)" (Tratado de Direito Penal. Parte Geral.12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 450).

Nesse contexto, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado para todos os réus, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea "a" c/c § 3º, do Código Penal, à vista da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, bem como da pena aplicada.

Descabida a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, III), destacando-se que a medida não é, de fato, socialmente recomendável, bem como a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

A detração penal (desconto do tempo de prisão provisória) para fins de abrandamento do regime prisional inicial (CPP, art. 387, §2º) é descabida na hipótese, por ausência do requisito objetivo.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus:

A) GABRIEL ISAC DA SILVA, Vulgo "Biel", às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com 1200 dias-multa, no piso, por incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

B) WEVERTON SOARES DOS SANTOS, Vulgo "Tom", às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 1.399 dias-multa, no piso, por incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; e

C) PAULO CÉSAR ELIZIÁRIO DOS SANTOS, às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com 1.800 dias multa, por incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma dos artigos 69 do Código Penal.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti (existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do CPP) pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que os réus permaneceram presos durante a instrução processual, para, ao final, serem condenados à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estavam traficando cocaína, tudo a revelar que a liberdade dos réus colocará em risco a ordem pública (CPP, art. 312), revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 282, §6º).

Dê-se à droga apreendida a destinação prevista no artigo 50, §3º a §5º, da Lei nº 11.343/06, caso ainda não adotada à providência.

Por fim, observo que, diante da prova no sentido de que os réus estavam realizando a mercancia da droga, resta indiscutível que o dinheiro e os bens apreendidos eram provenientes do tráfico. Nessa situação, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/2006, viável o perdimento do dinheiro e dos bens apreendidos em poder dele. Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento e mandado de prisão em regime fechado para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF; (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais e (d) notifique-se os acusados para o pagamento da pena de multa.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Fixo os honorários advocatícios do patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso e expedindo-se as competentes certidões.

Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as N.S.C.G.J.

P. I. C.

São Pedro, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA